

1502691-25.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor dos acusados.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1502691-25.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502691-25.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

MARCELO ROBERT MACIEL e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS NETO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, na noite de 19 de outubro de 2021, em horário incerto, transitando pela Rua Corpus Christi (antiga 36), na via pública, Parque Rodrigo Barreto, cidade e comarca de Arujá, o acusado trazia consigo e transportava drogas, quais sejam, 34 (trinta e quatro) porções menores e 1 (uma) porção maior de maconha (massa líquida de 181,72g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a exordial acusatória, o acusado era caronista em um veículo VW/FOX de um amigo, ocasião em que transportava drogas destinadas à traficância. Porém, o automóvel ocupado pelo acusado chamou a atenção de policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local.

O acusado, então, percebendo a aproximação da viatura, ordenou ao motorista que saísse do local imediatamente. Ato contínuo, o acusado arremessou pela janela do passageiro uma sacola.

Metros adiante o veículo foi abordado e seus ocupantes identificados. Com eles nada de ilícito foi encontrado; no veículo, havia apenas um aparelho celular no painel. Porém, a sacola dispensada pelo acusado foi recuperada, verificando-se que havia em seu interior 34 (trinta e quatro) porções menores e 1 (uma) porção maior de

maconha, além de mais um aparelho celular (fls. 68/71).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 06/10). Auto de exibição e apreensão (fls. 13). Laudo químico-toxicológico (fls. 15/17 e 195/197). Folha de antecedentes (fls. 40/43).

Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 46/50).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 74/75).

Foi recebida a denúncia em 17 de novembro de 2021 (fls. 91/95).

Foi deferido o pedido de restituição de coisa apreendida (fls. 78/80 e 104/105).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogado o réu ao final (fls. 208/212).

O Ministério Público apresentou memoriais, postulando pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, na primeira fase pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase incide a agravante da reincidência. Na terceira fase incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. Pugnou pela aplicação do regime fechado (fls. 376/384).

A defesa, por seu turno, em memoriais, requereu a absolvição do réu. Aduziu que em seu interrogatório o réu foi categórico ao afirmar que não estava vendendo entorpecentes. Afirmou que não foi realizada perícia datiloscópica na sacola apreendida. Destacou que os policiais que realizaram a abordagem do acusado praticaram diversas irregularidades na Comarca, em casos análogos, sendo necessária uma atenção especial ao conjunto probatório. Complementou que os policiais militares forjaram o acusado e várias outras pessoas, possuindo como alvo pessoas que já tiveram problemas com a justiça (fls. 388/391).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A materialidade está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, não restou satisfatoriamente comprovada.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Willian, policial militar, relatou que vinham fazendo um combate ao tráfico de drogas realizado no local, tem várias denúncias em mãos de lá e várias ocorrências anteriores. Aduziu que estavam patrulhando a via quando avistaram um veículo Fox parado no local onde há o trânsito dos compradores de entorpecente, e a porta do passageiro estava aberta. Contou que quando pararam atrás do veículo a porta fechou e o veículo saiu em marcha e andou por alguns metros. Falou que foi arremessada uma sacola para fora do veículo, do lado do passageiro, e o veículo parou logo à frente. Revelou que no veículo estavam o réu e o condutor do automóvel, eles foram abordados e nada de ilícito foi encontrado. Contou que seu companheiro voltou ao local onde a sacola foi arremessada, encontrou uma sacola com celular e quantidade de maconha dentro da sacola. Afirmou que eles foram conduzidos para a delegacia. Detalhou que os entorpecentes já estavam fracionados para a venda. Observou que o motorista do veículo disse na delegacia que ele não tinha conhecimento de que o réu estava carregando o entorpecente, mesmo se tratando de uma sacola de mercado com certa transparência. Externou que a sacola foi arremessada num terreno, é um descampado que fica na via. Noticiou que só estava o veículo com a porta aberta no local, quando viu a viatura fechou e saiu em marcha. Observou que realizaram a busca pessoal, fizeram a busca veicular, então seu companheiro voltou e encontrou a sacola. Mencionou que no dia estava chovendo.

A testemunha José Nilton, policial militar, disse que foi uma ocorrência baseada no disque denúncia de tráfico de drogas. Relatou que quando chegaram na rua se depararam com o veículo Fox, cor cinza, a porta do passageiro estava aberta e quando encostaram atrás eles fecharam a porta do passageiro onde estava o José e seguiram em marcha. Contou que eles arremessaram algum objeto num terreno que é cercado de bambu. Disse que após 100 ou 150 metros deram sinal de parada e eles

pararam. Afirmou que realizaram a abordagem, durante a busca pessoal e veicular nada de ilícito foi encontrado. Complementou que no terreno encontrou uma sacola de mercado que tinha entorpecentes e um aparelho celular, que foi arremessada do banco do passageiro onde estava o José. Disse que pegou a sacola, o Marcelo falou que não sabia de nada, mas disse que viu o José arremessando a sacola. Afirmou que foi dada voz de prisão, lidos os direitos constitucionais e encaminhados os infratores à autoridade responsável. Apontou que prestou mais atenção no lado do motorista e quem viu arremessando a sacola foi seu parceiro. Detalhou que na sacola havia porções de maconha, mas não consegue precisar o número. Falou que são vários disques denúncia do local e aquela rua já está virando uma cracolândia de tanto usuário que tem naquela via. Rememorou que na rua Corpus Christi, cem metros abaixo tem um terreno com uma cerca de bambu. Destacou que no dia estava chovendo, inclusive sujou sua bota de barro.

A testemunha Marcelo Robert, disse que estava no local quando o José Romão foi preso. Relatou que José passou em sua casa, o depoente o chamou para conversar, estava tomando uma cervejinha, ele ia para a casa dele porém o depoente pediu para esperar e depois o levaria de carro. Contou que ficaram uma meia hora, tomaram umas duas latas de cerveja, depois foram embora. Falou que descendo a Rua Corpus Christi onde reside, a uns cem metros de sua casa, a viatura já estava atrás e o fizeram parar. Afirmou que parou em frente à borracharia de um amigo seu, onde sabia que estava seguro, pois sabia da fama dos policiais de forjar, e o depoente tem passagem, então optou por parar ali. Afirmou que parou e desceu do carro normal, não jogaram nada, mas eles começaram a falar que tinham jogado, puxaram o depoente de canto e o agrediram para que falasse que o José tinha jogado pela janela as coisas, respondeu que não ia falar, eles continuaram a agredir, então o depoente falou que ia falar, sabendo que na delegacia não ia estar mais na custódia deles. Noticiou que foram ao pronto socorro e depois até a delegacia. Disse que na delegacia não falou nada, então o PM William retornou e disse: você não falou filha da..." xingou sua mãe, e disse que iriam levar só o José mas iam dar um jeito de forjá-lo mais para frente. Frisou que eles disseram que iriam ferrá-lo. Contou que na madrugada vieram, pediram para sair, eles tinham ido até seu irmão e pediram dinheiro para eles, apontou que sua avó e parentes se juntaram e deram três mil reais aos policiais. Destacou que à noite os policiais vieram com o celular particular deles, para falarem com a delegada de plantão. Falou que ficou nisto, falaram que iriam soltar, mas não sabiam que tinha pago para eles, assinou o papel e nem leu porque estava querendo ir embora. Asseverou que depois seu irmão contou que eles lhe pediram dinheiro para soltá-lo. Comentou que os policiais ameaçaram até sua filha na rua. Disse que não foi jogado e estava chovendo. Afirmou que na delegacia eles mesmos fizeram, porque lhe bateram muito então o depoente disse que iria falar. Revelou que está preso porque o forjaram, disse que seria mais fácil mudar e denunciar se não tivesse passagem, mas tem medo também por sua família. Exclamou que não está contando lorota, não tinha condições de se mudar.

O réu José Romão afirmou que tem 22 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro e pintor, ganhava mil reais por mês, é casado e tem uma filha de quatro anos, estudou até a sétima série, já foi processado por tráfico. Relatou que saiu em outubro de 2020 e estava há uns dois meses na rua e já ouvia falar do policial William e do parceiro dele, que usa o apelido de uma caveira. Falou que eles o abordaram perto da casa de sua mãe e já tinha ouvido falar que eles estavam forjando muita gente na cidade. Acrescentou que na abordagem estavam indo para a casa de sua mãe, sem nada, eles o seguraram por umas duas horas quando falou que tinha passagem, o agrediram, disseram que era traficante, que iriam prendê-lo e que iriam levá-lo para uma rua escura do Barreto que é a Rua Zero. Externou que disse aos policiais que não tinha necessidade, tem família e se regenerou do crime, inclusive trabalhou um ano e quatro meses na cozinha da cadeia. Afirmou que eles o liberaram e falaram que se o pegassem novamente ia ver como funcionava, o depoente seguiu sua vida normalmente. Contou que estava na casa do Marcelo, ele estava tomando uma cerveja, entrou e ficaram um tempo, começou a chover e o depoente falou que iria embora, mas o Marcelo falou que o levaria. Observou que quando entraram no carro e começaram a descer piscou um farol atrás e quando viu era viatura, então o Marcelo parou na

frente da borracharia. Informou que desceram e quando o policial William o viu ele grudou em sua camiseta e falou, era você mesmo que eu queria. Afirmou que ficou umas duas horas sentado em cima da mão, tomando chuva, o policial falou que iria preso e disse ao Marcelo que iria preso por causa do depoente. Noticiou que os levaram ao posto de saúde para fazer o exame de corpo de delito, chegando lá os deixaram com outros policiais, e eles saíram com a viatura deles. Comentou que o médico perguntou se tinha como soltar a algema para entrar um por vez na sala, o policial falou que não tinha porque o outro policial ia buscar o que faltava para fazer a denúncia, então o depoente falou que devia ter ido buscar a droga, porque os pegaram sem nada. Disse que o policial voltou com a viatura dele, uma Traiblazer branca, vermelha e preta, colocou o depoente no canto e perguntou se ia trocar ideia. Afirmou que os policiais começaram a lhe pedir dinheiro, o depoente respondeu que não tinha. Externou que foi preso dos 18 até 21 anos e estava se regenerando. Exclamou que em momento nenhum viu sacola ou droga, eles o jogaram na viatura e falou que estava preso. Disse que na delegacia não teve a oportunidade de dar depoimento, eles falaram que viram jogando a sacola, o depoente até falou com os policiais civis que se tivesse com alguma coisa iria assumir. Comentou que elogiou a polícia civil, porque eles abordam e se não tem nada mandam embora, mas os policiais militares estão forjando todo mundo no Barreto. Pontuou que o policial com anel de caveira mostrava o anel e dizia que gostava de matar na faca. Destacou que mostrou onde morava e por qual motivo não foram em sua casa. Confidenciou que não se conforma e está revoltado, sabe que já tem passagem por tráfico e se falasse a verdade para a doutora iria pegar uma condenação mínima, mas dá revolta porque já encontrou um monte de gente no CDP forjado só pelo mesmo policial. Frisou que não falou nada na delegacia. Afirmou que se conseguir pegar o GPS da viatura para ver a trajetória que fizeram vai verificar que pararam no posto de saúde, foram até a delegacia, demoraram uns minutos e voltaram. Ressaltou que não viu sacola e nem nada até agora. Noticiou que quando sair da cadeia vai se mudar de cidade porque com uns policiais desses não dá para morar. Disse não saber se os policiais estavam de campana. Admitiu que a rua é ponto de tráfico, porém o Marcelo mora lá e o depoente tinha saído da casa dele. Informou que estava em regime aberto e foi preso umas 20h, tinha que se recolher à residência às 22h.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Pela prova colhida nos autos, não há certeza de que os réu possuía drogas para fins de tráfico e nem mesmo que a abordagem foi realizada nos moldes relatados pelas testemunhas policiais.

Os exames toxicológicos confirmaram a natureza entorpecente das drogas, sendo constatado que se tratava de 181,72 g maconha.

Em seu interrogatório, como se pode observar, o réu negou a prática do delito de tráfico, alegando que estava de carona com Marcelo, que o levaria até sua casa em razão da chuva que havia no momento, quando vieram a ser abordados pelos policiais. Em seus relatos o réu e a testemunha Marcelo afirmaram que os policiais os agrediram, demandaram dinheiro para os soltarem, os levaram até o pronto socorro algemados, e forjaram a apreensão de drogas no intuito de prejudicá-los, circunstâncias estas que, segundo eles, já vinham ocorrendo com outros indivíduos do bairro que tinham passagem criminal e vinham a ser abordados.

Importa observar que tanto a testemunha Marcelo, quanto o réu José Romão, negaram que teriam confessado a responsabilidade pelo crime ou que teriam dito aquilo que consta no termo de depoimento do inquérito policial.

Pelo contrário, ambos afirmaram que, além de ter sido demandado dinheiro pelos policiais para que fossem liberados, não chegaram a ser devidamente ouvidos em solo policial.

Em arremate, o réu José Romão e a testemunha Marcelo mencionaram a ocorrência de perseguição policial, com ameaça de futura apreensão, noticiando que seriam inúmeros os indivíduos do CDP que teriam sido apreendidos em situações análogas, com apreensões originadas em fatos forjados.

Como se pode observar, os relatos do réu e testemunha são, no mínimo, incomuns, tendo sido feitas imputações graves concernentes à conduta dos policiais que efetuaram a abordagem, com menção a diversas ações que destoam da regra de

comportamento legal condizente com o cargo ocupado pelos agentes da lei. Os policiais apresentaram singela narrativa dos fatos, limitando-se a afirmar que após o recebimento de denúncias sobre a prática de comércio espúrio se dirigiram até o local dos fatos onde abordaram os acusados. Disseram que eles estavam num veículo Fox, que prosseguiu em marcha, sendo atirado pela janela do lado do passageiro uma sacola, na qual posteriormente foram encontrados entorpecentes. Neste ponto, cabe observar que não é possível depreender do relato policial, com a segurança necessária, que o objeto atirado do veículo onde se encontrava o réu José Romão era uma sacola.

Importa obter, também, que a sacola em comento foi encontrada por um dos policiais momentos após a abordagem, sendo localizada num terreno baldio, não sendo possível descartar que poderia pertencer a terceiro que estaria no local ou mesmo que ali teria sido abandonada há tempos, sendo localizada pelos milicianos por casualidade.

Com efeito, no caso sub judice, efetivamente de relevante existe apenas o alegado encontro de entorpecentes pelos policiais militares e o depoimento de tais policiais no sentido de que o réu era quem transportava a droga.

Observo, de outro giro, que nos depoimentos dos policiais estes não informaram terem visto o réu praticando efetivamente tráfico de drogas, pelo contrário, apenas abordaram o réu no veículo que estava na rua supostamente conhecida como ponto de tráfico.

Ainda, não há notícia de realização de campana que pudesse permitir aos policiais o acompanhamento de ações que indicassem efetiva prática de comércio de drogas pelo acusado.

Da mesma forma, não se realizou qualquer perícia dactiloscópica confirmando as digitais do acusado José Romão na sacola, nem mesmo após a formulação do pedido em sede policial em duas oportunidades. Ressalte-se, ainda que nada foi encontrado em poder do réu ou dentro do veículo.

Frise-se, ainda, por oportuno, que sequer houve a vinda aos autos de perícia no celular apreendido com o acusado, com conversas entre ele ou com terceiros que indicassem a venda de drogas.

Insta obter ainda que, no caso particular dos autos, a combativa defesa logrou êxito em produzir elementos probatórios idôneos capazes de captar o convencimento do magistrado, fazendo frente às provas produzidas pelo órgão acusador, influenciando de forma decisiva no julgamento.

A par de tudo isso, como sói ocorrer, não foi trazida qualquer outra testemunha, que estivesse presente no momento do flagrante, mesmo havendo relato de tratar-se de local supostamente conhecido como ponto de venda de droga, sendo, neste caso, pouco crível a ausência de outros usuários ou de terceiros no local, no momento do flagrante. Saliento que os próprios policiais afirmam que o local é bem conhecido como ponto de venda de drogas e que haveria fluxo de usuários na via, havendo atuação policial no local visando combate ao tráfico de entorpecentes.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é composta por depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos. A presente situação não se amolda, todavia, a esta regra, lembrando que o réu negou o tráfico de drogas, não havendo, do mesmo modo, outros indicativos seguros da ocorrência do comércio espúrio pelo acusado.

Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho prestado por policiais, mas de não olvidar ou ignorar o julgador a possibilidade de ocorrência de falhas perpetradas por estes no exercício de sua função, que podem até incluir imputações precipitadas, pouco apuradas, apressadas ou mesmo injustas. Ademais, experiências recentes na Comarca, inclusive na 2ª Vara, em prisões por tráfico de drogas, em situações semelhantes, com depoimentos orais análogos, nas quais surgiram dúvida sobre a dinâmica dos fatos, reforçam a necessidade de exame mais cuidadoso do conjunto probatório. Há, aliás, notícias de que o Ministério Público, em virtude de algumas irregularidades identificadas em relação a determinados testemunhos policiais (especificamente em relação aos profissionais

ouvidos nos presentes autos) em processos análogos, tem envidado esforços para apurar melhor alguns episódios e condutas de agentes, conforme ofício encaminhado a este juízo. Impõe-se, portanto, uma atenção ainda maior à prova amealhada aos autos em casos como o presente.

Neste passo, transcrevo parte dos argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante no julgamento dos autos n. 1500692-03.2022.8.26.0535:

Como regra não se deve negar credibilidade ao relato dos policiais, agentes públicos que, a priori, não possuem interesse no resultado do processo. Porém, experiências recentes na Comarca em prisões por tráfico de drogas em situações análogas, nas quais surgiram elementos objetivos colocando dúvida sobre a dinâmica dos fatos, indicam necessidade de exame mais cuidadoso das provas.

Mais do isso, são reiterados os processos penais na Comarca resultantes de atuação específica dos mesmos policiais militares aqui envolvidos ou ao menos um deles em que durante a instrução aportaram denúncias de supostos flagrantes forjados, prisões arbitrárias, agressões, ameaças, entre outras irregularidades igualmente graves.

Tais relatos não partiram apenas dos respectivos dos réus, nem de uma única ação penal, mas também de testemunhas, familiares e pessoas sem vínculos com os acusados, nas mais diversas situações, inclusive em processos que tramitam em Vara diversa. Há notícia de instauração de diversos procedimentos na Corregedoria da Polícia Militar e outras providências tomadas pelo Ministério Público a respeito dessas denúncias.

Não se está a afirmar que os policiais efetivamente praticaram aquelas irregularidades ou as sugeridas neste processo, prova dessa natureza deve ser avaliada com extrema cautela e em ambiente processual adequado. Mas sim que a diversidade, consistência e reiteração do padrão das denúncias, sempre envolvendo os mesmos policiais, não podem ser ignoradas.

Por isso, especificamente nas ações penais que apuram tráfico de drogas nesta Comarca a partir de diligências realizadas por estes policiais, excepcionalmente seus depoimentos devem receber força probatória relativa.

Em toada semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. A versão policial isolada sobre a prática do crime não forma conjunto probatório suficiente para sustentar a convicção sobre a destinação da droga apreendida e, portanto, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.16.010381-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018).

Neste sentido também é o ensinamento de Gustavo Badaró:

Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do artigo 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelos simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por ele investigados.

Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se demonstrem harmônicos entre si (BADARÓ, Gustavo Henrique; Processo Penal. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 477/478). (Grifos nossos)

Em sentido semelhante ao aqui exposto, esclarece, de forma muito didática, Aury Lopes Jr:

Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.

Contudo, é recorrente o Ministério Público arrolar como testemunhas apenas os policiais que participaram da operação e da elaboração do inquérito. Busca, com isso, judicializar a palavra dos policiais para driblar a vedação de condenação "exclusivamente" (art. 155 do CPP) com base nos elementos informativos colhidos na investigação. Na continuação, deparamo-nos com sentenças condenatórias em que são utilizados os elementos do inquérito e o depoimento dos policiais em juízo.

No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois a condenação se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no art. 155 do CPP. Portanto, se não há impedimento para que os policiais deponham, é elementar que não se pode condenar só com base nos seus atos de investigação e na justificação que fazem em audiência." (2019, p.462)

Aliás, na linha do que está sendo exposto, se a ideia fosse tomar como absoluta e incontestável toda e qualquer declaração prestada por testemunhas policiais no bojo do processo penal, despicienda seria a instrução probatória e até mesmo a valoração da prova colhida pelo Juiz de Direito. A presunção de inocência, princípio que informa todo o sistema processual penal, e que está prevista como garantia constitucional, também seria invariável e inevitavelmente fulminada.

Outrossim, como este juízo sempre vem asseverando, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações dos policiais que efetivaram a prisão do acusado, até porque, como consignado alhures, é natural que estes objetivem legitimar, até inconscientemente, sua própria atuação. Por oportuno, não se pode deixar de registrar, em crimes de natureza diversa do ora apurado, a par dos depoimentos policiais, são em regra produzidos outros elementos de prova, de origens distintas, a exemplo de testemunhos de terceiros, oitiva da vítima, com reconhecimento de pessoa e de objeto, etc, o que sem dúvida contribui para a realização de uma instrução processual mais robusta, com possibilidade de uma construção mais sólida da culpabilidade do agente.

Por um outro viés, estes mesmos policiais já dispõem, nos dias atuais, de outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, conferindo às suas declarações um caráter de veracidade quase irrefutável, como já se pôde constatar em outras oportunidades, em que os policiais se valeram, inclusive, de gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações. Aliás, é pouco compreensível que nos dias de hoje, no estágio em que se encontra a tecnologia, haja ainda uma utilização tão tímida de aparatos e instrumentos de captação e gravação das abordagens policiais.

Pontua-se também, mais uma vez, que não foi trazida qualquer testemunha distinta do policial que pudesse corroborar a versão acusatória, o que certamente robusteceria a prova acusatória. Neste sentido são as palavras do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:

Parece-nos cauteloso que o magistrado, visualizando, em processos de apuração de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, um rol de testemunhas de acusação formado somente por policiais, indague os mesmos a razão pela qual não se obteve nenhuma pessoa, como testemunha, estranha aos quadros da polícia. Essa verificação é essência, pois uma apreensão de drogas feita à vista de inúmeras pessoas, em local público, por exemplo, pode perfeitamente contar com o testemunho de pessoas que não sejam policiais. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2009, p. 353).

Assim, cumpre indagar, ante aquilo que foi exposto, se o quanto relatado pelo policial pode, na hipótese em tela, ser considerada uma prova robusta e coerente para fins de fundamentalmente arrimar uma condenação por tráfico de drogas. No entendimento deste Juízo, não é.

Forçoso, in casu, verificar que, tendo negado o réu a propriedade ou porte da droga apreendida em juízo, e não havendo, além da declaração dos policiais, qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor dos acusados.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não comprovada - Indícios insuficientes para formar convicção nesse sentido - Réu preso em companhia de menor reconhecido e indicado como traficante - Ausência de atos seguros e concretos vinculando suas ações - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido - (TJSP, APELAÇÃO Nº: 990.09.047397-5 - COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA APTE WELLINGTON DA SILVA SANTOS APDO : Ministério Público).

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas e mesmo que se considere pouco crível a versão apresentada pelo réu, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas pelo acusado.

Registre-se que, como frisado alhures, a versão do réu pode não ser tão convincente, e ao menos o histórico de José Romão mostra-se inegavelmente desfavorável (fls. 40/43). Não obstante, à vista das circunstâncias apresentadas, e verificadas, como ressaltado, em processos análogos, outra solução não há que a absolvição.

Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor do réu, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Como é cediço, em casos de dubiedade, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

"...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos."

"Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas



penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo”

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi autor do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câmara, de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

No mais, conforme leciona o Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 150 ), membro do Ministério Público de São Paulo:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Quando se tem presente, salientou Malatesta, que a condenação não pode basear-se senão na certeza da culpabilidade, logo se vê que a credibilidade razoável – também mínima – da inocência, sendo destrutiva da certeza da culpabilidade, deve, necessariamente, conduzir à absolvição”.

Com efeito, uma sentença judicial condenatória deve ser embasada em elementos objetivos, contundentes e sólidos. Em verdade, para fins de condenação criminal, a intuição deste julgador não tem qualquer importância. Não basta a crença, deve haver certeza.

Novamente, colaciona-se o escólio do Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 15):

A respeito, obtempera Heleno Cláudio Fragoso que “a condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de nossa mente em torno da existência de certa realidade”. Mesmo a íntima convicção do Juiz – pondera Sabatini –, como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação (g.n.), não é verdadeira e própria certeza (...); no lugar da certeza, em espécie tal, tem-se a simples crença.

O entendimento do nobre membro ministerial é de rara sabedoria e desmerece contestações.

Como se vê, no caso em tela, mesmo diante da suposta localização da droga, e considerando o teor dos interrogatórios, as inconsistências apontadas, e o conjunto

probatório produzido, e que a prova produzida pelo órgão acusador se restringe, basicamente, aos testemunhos policiais - que são a reprodução das declarações que constam em inquérito - os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com segurança necessária que o réu praticava o crime inserto no art. 33 da lei 11.343/06. Com isso, destaque-se, não se conclui pela necessária ocorrência de um flagrante forjado, mas sim, pressupõe-se que, havendo dúvida do que ocorreu na data dos fatos, deve ser aplicada a máxima mencionada, já que a dúvida milita em favor do acusado.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e ABSOLVO o réu JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS NETO, da imputação que lhe foi dirigida, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, com urgência.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Cautelas e comunicações de estilo.

Havendo demais bens ou valores apreendidos, excetuado o veículo acima, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

P.I.C.

Aruja, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA